

1520043-10.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... inicial, a ressaltar que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520043-10.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520043-10.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237942/2022 - DEIC-4ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 27111711 - DEIC-4ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2237942 - DEIC-4ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO FARIA DIAS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Drª. Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

DANILO JORGE BERNAL e RICARDO FARIA DIAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 30 de agosto de 2022, por volta de 20h00, na Avenida Adriano Bertozzi, 1200, Parque do Carmo, nesta cidade e comarca de São Paulo, os acusados, previamente ajustados, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, traziam consigo, armazenavam, guardavam e transportavam, para fins de tráfico, 39 tijolos e 04 porções de cocaína, com peso líquido total de 39,49 Kg, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narram os autos que os policiais receberam uma denúncia anônima que comunicava que o caminhão Ford Cargo, branco, de placas DGE5A55, era utilizado por organização

criminosa para o transporte de armas.

Após diligências, o referido caminhão foi localizado em tráfego pela Avenida Jacú Pêssego, ocupado pelos acusados Danilo, que dirigia o veículo, e Ricardo, que ocupava o banco do passageiro.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. Ocorre que, diante das respostas evasivas e desconexas apresentadas pelos réus, decidiram os policiais pela condução dos acusados e do veículo à delegacia, onde Danilo confessou informalmente que transportavam drogas indicando um compartimento oculto na carroceria do caminhão, onde uma chapa de alumínio fora instalada, deixando um vão, um fundo falso, no qual os entorpecentes estavam armazenados.

Os réus foram presos em flagrante delito no dia 31 de agosto de 2022, tendo sido as prisões convertidas em preventivas após decisão proferida em audiência de custódia (fls. 68/71).

Os acusados foram citados e notificados (fls. 181 e 184) e apresentaram defesa preliminar no dia 24 de novembro de 2022 (fls. 154/156).

A denúncia foi recebida no dia 27 de setembro de 2022, oportunidade em que foram mantidas as prisões dos acusados (fls. 168/169).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final, os réus foram interrogados (fls. 225/226).

Declarada encerrada a instrução do feito, e convertidos os debates orais em alegações escritas, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito.

Requeru o afastamento da confissão para fixação da pena base, rechaçando também a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11343/2006, impondo-se o regime fechado para cumprimento da penas aplicadas (fls. 230/240).

A defesa do acusado RICARDO suscitou irregularidades na prisão em flagrante, notadamente em razão do uso de algemas no réu e na condução dos réus para delegacia diversa da área de circunscrição da abordagem, contrariando o teor da Recomendação DGP-02, de 08/09/92. Invocou a teoria da "perda de uma chance" para aduzir que foi impedido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo de protocolizar recurso de habeas corpus, tendo sua defesa cerceada. Apontando contradições e fragilidades nos depoimentos dos policiais ouvido em Juízo, requereu a absolvição por insuficiência probante, considerando que a prova amealhada aos autos resume-se ao depoimento dos policiais. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima, com o cômputo da confissão, a incidência do parágrafo 4º da Lei 11.343/06, a imposição de regime aberto para cumprimento da pena, com substituição por pena restritiva de direitos e recurso em liberdade, revogando-se a prisão preventiva decretada. Requereu, por fim, a gratuidade processual (fls. 250/280).

A defesa do réu DANILO, por seu turno, igualmente discorreu sobre ilegalidades verificadas na abordagem policial, reputando-a abusiva em razão da inexistência de fundada suspeita para a busca, bem como por contrariar o teor da Recomendação DGP-02, de 08/09/92. Requereu a revogação da prisão preventiva do réu e o trancamento da ação penal, diante do abuso verificado na abordagem policial. Apontando contradições e fragilidades nos depoimentos dos policiais ouvido em Juízo, e invocando também a teoria da "perda de uma chance", postulou a absolvição por insuficiência probante. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima, com o cômputo da confissão, a incidência do parágrafo 4º da Lei 11.343/06, a imposição de regime aberto para cumprimento da pena, com substituição por pena restritiva de direitos e recurso em liberdade, revogando-se a prisão preventiva decretada (fls. 282/294).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, afasto as alegações da Defesa quanto à irregularidade da prisão em flagrante, que culminariam na nulidade da ação penal, pois a análise da higidez da prisão em flagrante já foi realizada no momento oportuno, consoante decisão de fls. 68/71, não se constatando máculas.

No que tange ao alegado abuso na busca pessoal e veicular efetivada, inclusive

mediante não observância à determinação regulamentar, tampouco o reputo presente. Na hipótese dos autos, os depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório revelaram que a abordagem decorreu de denúncia anônima com expressa indicação dos dados do veículo que transportava entorpecentes. O fato de não reduzida a termo a denúncia anônima é insuficiente para lhe retirar a higidez, ainda que tal medida fosse de boa cautela, para maior confiabilidade da prova. É notório, contudo, que os denunciantes de delitos de tráfico recusam-se à identificação, pelo compreensível temor de represálias, razão pela qual a formalização da denúncia teria pouco efeito prático, a despeito de não retirar sua utilidade, frise-se.

De igual modo, o aprofundamento da busca veicular decorreu das repostas contraditórias apresentadas pelos réus aos policiais no momento da abordagem e entrevista pessoal. Tal circunstância, aliada à denúncia anônima sobre o transporte de entorpecentes, é suficiente para completar o quadro de fundada suspeita que ensejou o encaminhamento do veículo à delegacia para busca mais minuciosa, cuja realização seria inviável na via pública, no período noturno. Ademais, o encaminhamento à delegacia de área diversa daquela dos fatos não macula a diligência, por se tratar de recomendação administrativa.

Assim, e considerando também que nem mesmo os réus alegaram em interrogatório judicial quaisquer abusos ou violações de direito durante a busca pessoal e veicular efetivadas, afastos as teses defensivas relativas à ilegalidade da abordagem e busca veicular. Vale dizer, a despeito do esforço argumentativo dos combativos defensores, não há fundamento para que sejam desentranhadas dos autos as provas da materialidade delitiva.

No mérito, a ação deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17 e 105/107), pelo auto de depósito (fl. 18), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13 e 110/111), pelo laudo de constatação (fls. 20/23 e 114/117) e pelo laudo químico toxicológico (fls. 209/211), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl.05) e pela prova oral produzida em juízo.

A testemunha Márcio Cabral dos Santos, policial civil, disse que estava trafegando na avenida Jacú Pêssego em busca de caminhão indicado em denúncia sobre tráfico de drogas. Não houve registro da denúncia, foi anônima, mas era apontada a placa do veículo. Realizada a abordagem, os réus apresentaram respostas divergentes sobre o destino do caminhão, o qual estava vazio. Em razão disso, e considerando as informações da denúncia anônima, o réu Danilo apontou o compartimento onde estavam os entorpecentes, que ficava entre a cabine e a carroceria. Ele não indicou nomes de pessoas para quem entregaria as drogas. Ricardo era o motorista, o caminhão estava no nome dele, salvo engano. Ricardo disse que estava apenas dirigindo o veículo e que não sabia Danilo estava no passageiro, na ocasião estava de barba. Não conhecia os réus anteriormente. Foram encontrados tijolos de cocaína no compartimento, cerca de 30kg. Não se lembra se foram encontradas anotações sugestivas de tráfico, apenas um celular, que salvo engano foi submetido a perícia. Conversou com os dois réus no dia dos fatos, o da direita da tela estava de barba naquele dia.

A testemunha Ricardo Rodrigo Luiz Macedo, policial civil, corroborou o relato do colega. Disse que receberam uma informação anônimas em diligências de campo sobre o caminhão e sua placa. O réu do lado esquerdo da tela (salvo engano Danilo) conduzia o veículo e Ricardo (o do lado direito) estava como passageiro. O local estava escuro, não era possível fazer vistoria mais minuciosa no veículo, razão pela qual levaram o automóvel para o DEIC. Ali, o condutor do passageiro indicou a compartimento secreto onde estava a droga. Ricardo disse que ganhava R\$ 500,00 por peça transportada. Havia 39 tijolos de cocaína. Foram apreendidos alguns papéis e aparelho celular. Os réus admitiram que no fundo do caminhão havia um fundo falso. Não conhecia os réus anteriormente. Não se lembra o teor dos papéis, mas não pareciam diretamente ligadas da traficância. Não foi feito relatório da denúncia anônima.

Em solo policial, os réus optaram por permanecer em silêncio.

Ouvido em Juízo, o réu Danilo disse que foi contratado para fazer um frete, ganharia cerca de R\$ 2.000,00, mas não sabia que havia drogas ali. Um indivíduo chamado Jorge, a quem conhecem como Negão, pediu para que ele aceitasse passar o caminhão para o nome dele, que isso o ajudaria, pois poderia usar para fazer fretes. Nunca foi preso ou processado criminalmente. Trabalhava como funileiro, ganhava cerca de R\$ 200,00 por semana. Parou na oitava série. Soube apenas posteriormente que o caminhão tinha um fundo falso. No dia dos fatos, indicou o local onde havia o fundo falso.

O réu Ricardo, por seu turno, disse que recebeu a proposta de um indivíduo chamado Jorge, conhecido como Negão, para fazer um transporte junto com Danilo. Iria receber R\$ 2.000,00, a função era apenas acompanhar Danilo. Sabia que havia drogas no local. Quem indicou o fundo falso foi Danilo. Nunca foi preso anteriormente. Trabalhava como vendedor autônomo, ganhava de R\$ 2.000,00 a R\$ 3.000,00. Terminou o colegial. Tanto ele quanto Danilo tinham ciência das drogas que estavam ali. Contrariamente ao quanto alegado pela defesa, as provas colhidas, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamentam o decreto condenatório. A versão apresentada pelos acusados, confessando o crime, está corroborada pelas provas acostadas aos autos, não havendo dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar os acusados.

Destaco que já foram afastadas as alegações relativas à ilegalidade da abordagem policial e da busca veicular, pelo que a prova daí decorrente há de ser tida como válida.

Saliente-se, nesse particular, que depoimento dos policiais ouvidos em Juízo fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, não se devendo desconsiderar o teor do depoimento apenas pela sua condição funcional.

Nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206, primeira parte, do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

O depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que fazem parte dos quadros da polícia não foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. "Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo" STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e "Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304.

Assim, a prova produzida pela acusação autoriza a condenação do acusado pelo crime de tráfico, na medida em que absolutamente firmes os depoimentos no sentido de que foi encontrada elevadíssima quantidade de entorpecentes (mais de 39 kg) na posse dos denunciados.

Ainda que os acusados não tenham sido flagrados durante a efetiva entrega de entorpecentes a terceiros, na tradição, devem ser condenados nos termos da imputação inicial, a ressaltar que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminoso, as circunstâncias da prisão,

bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

Cabe, também, afastar a assertiva da Defesa quanto à existência de contradições nos depoimentos dos policiais. Ora, tratando-se de pessoas, não há que se exigir precisão absoluta nas narrativas, visto que a percepção humana é mesmo falha, sendo suficiente para a credibilidade dos relatos que se mostrem coesos em seus aspectos substanciais, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, diversamente do que pretende fazer a Defesa..

Assim, à luz do quadro fático amalhado aos autos, a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes é imperiosa.

Passo à dosimetria das penas.

Com relação ao acusado Danilo Jorge Bernal

Na primeira fase, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, pelo que fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a circunstância atenuante da confissão, inviável a redução da pena abaixo do mínimo-legal, nos termos do enunciado da Súmula nº 231 do C. STJ.

Na terceira fase, a despeito do esforço argumentativo ministerial, reputo inviável o afastamento do redutor de pena previsto na lei especial. Embora a quantidade de drogas por ele transportada seja elevadíssima, tal fato, isoladamente, não pode obstar a aplicação do redutor, nos termos do entendimento majoritário dos tribunais superiores. Na hipótese, o réu é primário e de bons antecedentes, não tendo sido amalhados aos autos outros elementos comprobatórios de que já esteja imerso em atividade estruturada do comércio de drogas. Daí porque o fato de estar transportando quantidade elevada de drogas, isoladamente, não afasta a possibilidade de que seja iniciante na traficância, fazendo jus ao privilégio legal.

Para modulação da fração de redução, contudo, viável o embasamento na quantidade de entorpecentes, pelo que, no caso em tela justifica-se a redução em fração superior à máxima, no montante de 1/3 (um terço), considerando o total de 39 kg de cocaína apreendidos. Totalizando a pena final, portanto, em 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa.

Nesse sentido é o recente julgado: "É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena." (HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022).

Desse modo, reconhecido o privilégio, diante da quantidade da pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída, bem como por uma pena de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Com relação ao acusado Ricardo Faria Dias

Na primeira fase, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, pelo que fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a circunstância atenuante da confissão, certo não ser possível reduzir a pena abaixo do mínimo-legal, nos termos do enunciado da Súmula nº 231 do C. STJ.

Na terceira fase, a despeito do esforço argumentativo ministerial, reputo inviável o afastamento do redutor de pena previsto na lei especial. Embora a quantidade de drogas por ele transportada seja elevadíssima, tal fato, isoladamente, não pode obstar a aplicação do redutor, nos termos do entendimento majoritário dos tribunais superiores. Na hipótese, o réu é primário e de bons antecedentes, não tendo sido amealhados aos autos outros elementos comprobatórios de que já esteja imerso em atividade estruturada do comércio de drogas. Daí porque o fato de estar transportando quantidade elevada de drogas, isoladamente, não afasta a possibilidade de que seja iniciante na traficância, fazendo jus ao privilégio legal.

Para modulação da fração de redução, contudo, viável o embasamento na quantidade de entorpecentes, pelo que, no caso em tela justifica-se a redução em fração superior à máxima, no montante de 1/3 (um terço), considerando o total de 39 kg de cocaína apreendidos. Totalizando a pena final, portanto, em 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa.

Nesse sentido é o recente julgado: “É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.” (HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022).

Desse modo, reconhecido o privilégio, diante da quantidade da pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída, bem como por uma pena de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, os réus DANILO JORGE BERNAL e RICARDO FARIA DIAS GABRIEL MARTINS DE ARAUJO, qualificados nos autos, às penas privativas de liberdade de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada um deles no mínimo legal. As penas privativas de liberdade de ambos os réus são substituídas por penas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, sendo ainda calculada a pena de multa na forma prevista e no valor mínimo fixados pelo artigo 43 da Lei nº 11.343/2006, por não existir haver informadas nos autos para sua exacerbação. Diante das penas aplicadas de regime de cumprimento, não mais se justifica a prisão preventiva dos réus, pelo que a revogo. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Os réus são primários e poderão recorrer em liberdade, tendo em vista a pena fixada e o regime de seu cumprimento.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para cumprimento da pena fixada.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor do FUNAD.

Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA